

<제1편 총설.제1장 민사소송.제3절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>

I. 의의

- 민사소송의 이상이란 민사소송제도가 지향해야 할 최고지도원리를 의미한다. 민사소송법 제1조 제1항에서 법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.고 규정하고, 제2항에서 당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.고 규정하여 이를 명문화하고 있다. 민사소송의 3대 이상은 적정·공평, 신속, 경제이다. 적정·공평은 재판의 내용이 실제적 진실에 부합하고 절차적으로 당사자에게 평등한 기회를 부여해야 한다는 원칙이다. 신속은 '지연된 정의는 정의가 아니다'라는 격언처럼 적시에 판결을 내리는 것을 의미하며, 경제는 최소한의 비용과 노력으로 최대의 분쟁해결 효과를 거두는 것을 목표로 한다. 이러한 소송의 이상을 구체적인 소송수행의 지침으로 전환한 것이 신의성실의 원칙(이하 '신의칙')이다. 이는 사법상 신의칙이 소송법 분야로 유입된 것으로, 당사자가 소송상 권능을 행사하거나 의무를 이행할 때 상대방의 신뢰를 배반하지 않도록 성실히 행동해야 한다는 윤리적 법원칙이다. 2002년 민사소송법 개정을 통해 명문으로 도입됨으로써 단순한 선언적 의미를 넘어 실증법상의 구속력을 가진다.

II. 적용범위

1. 적용여부

- 과거에는 민사소송이 엄격한 법정절차에 의하므로 주관적 요소를 포함하는 신의칙의 적용을 부정하는 견해도 있었으나, 현대 소송법학에서는 이를 당연히 인정한다. 민사소송은 국가와 당사자, 당사자 상호 간의 법적 공동체 형성 과정이므로 그 구성원 간의 신뢰 보호는 필수적이다. 다만, 절차의 안정성을 해치지 않는 범위 내에서 보충적으로 적용되어야 한다는 점에 유의해야 한다.

2. 학설

(1) 보충적 적용설

- 개별적인 법규나 법해석으로 해결할 수 없는 경우에만 적용된다는 입장이다.

(2) 선택적 적용설[판례]

- 부제소합의에 위반하여 제기된 소에 대해 권리보호의 이익을 부정하면서, 신의칙의 원칙에 반한다고 보는 입장이다.

(3) 검토

- 판례와 같이 개별법규가 적용될 사안인지 여부는 불분명한 경우가 대부분이므로 선택적 적용설이 타당하다고 보인다.

III. 적용모습

1. 소송상태의 부당형성의 금지

- 당사자가 자기에게 유리한 소송상태를 만들기 위해 부당한 수단을 사용하는 것을 금지하는 원칙이다. 소송요건의 작위적 형성으로서 대한민국 법원에 재판관할권을 강제로 발생시키기 위해 허위의 주소를 기재하거나, 전속관할을 회피하기 위해 허위의 공동피고를 추가하는 행위가 이에 해당한다. 또한 증거의 조작 및 방해와 관련하여 상대방의 입증을 곤란하게 할 목적으로 증거물을 인멸하거나, 증인이 출석하지 못하도록 협박하는 행위 등은 신의칙에 반한다. 판례는 당사자 일방이 증거를 인멸한 경우, 그로 인해 입증이 곤란해진 사실을 상대방의 주장대로 인정하거나 입증책임을 전환하는 등의 제재를 가한다.

2. 선행행위와 모순되는 거동의 금지

- 이른바 금반언의 원칙으로, 당사자가 이전에 행한 명시적·묵시적 거동과 모순되는 소송행위를 함으로써 상대방의 정당한 신뢰를 해치는 것을 금지한다. 적용 요건으로 첫째, 당사자의 선행행위가 존재해야 하며, 둘째, 상대방이 그 선행행위를 신뢰하고 소송상 지위를 구축했어야 하고, 셋째, 후행행위가 선행행위와 정면으로 배치되어야 한다. 구체적 사례로는 상대방의 제소에 대하여 본안판결을 구하며 응소한 자가 나중에 소송요건의 흠결을 주장하며 각하를 구하는 경우나, 제1심에서 특정 사실에 대해 다투지 않겠다고 명시적으로 표명한 후 항소심에서 이를 다시 다투는 행위 등이 이에 속한다. 다만, 판례는 강행법규 위반을 알고도 계약을 체결한 자가 나중에 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙 위반이 아니라고 보아 절차의 엄격성을 유지한다.

3. 소권의 실효

- 관리자가 상당한 기간 소권을 행사하지 않아 상대방이 더 이상 권리행사가 없을 것으로 믿을만한 정당한 사유가 생긴 경우, 그 소권의 행사를 허용하지 않는 원칙이다. 제척기간이나 소멸시효 제도를 보완하여 법적 안정성을 도모하고 상대방의 방어권 침해를 방지하기 위한 취지를 가진다. 판례는 실효의 원칙이 적용되기 위해 상당한 기간의 경과와 권리불행사에 대한 정당한 신뢰라는 두 가지 요건이 충족되어야 한다고 본다. 단순히 기간이 오래되었다는 사실만으로는 부족하며, 관리자가 권리를 행사하지 않을 것 같은 태도를 보여야 한다. 해고된 근로자가 수년간 아무런 이의를 제기하지 않다가 갑자기 해고무효확인소송을 제기하는 경우 등이 대표적인 실효의 사례로 검토된다.

4. 소권의 남용금지

- 외형상으로는 소송상의 권리행사처럼 보이나, 실질적으로는 상대방에게 고통을 주거나 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 소를 제기하는 경우 이를 허용하지 않는 것이다. 이미 확정판결을 받은 사안에 대하여 동일한 목적의 소를 반복적으로 제기하는 경우, 송소할 가능성이 전혀 없음에도 상대방을 괴롭히기 위해 제소하는 경우, 기판력의 저축을 피하기 위해 형식적인 당사자만 바꾸어 소를 제기하는 경우 등이 해당한다. 판례는 판결의 편취(허위의 주소나 증거로 승소판결을 받아내는 행위)를 소권 남용의 전형적인 형태로 본다. 이 경우 확정판결의 효력을 부인하거나, 강제집행을 저지하는 소송에서 신의칙 위반을 근거로 당사자의 청구를 기각한다.

IV. 위반의 조사 및 효과

1. 직권조사사항

- 신의칙 위반 여부는 소송요건에 준하는 사항으로서 당사자의 항변이 없더라도 법원이 직권으로 조사하여야 한다. 이는 공공의 이익과 소송절차의 정당성을 보호하기 위함이다. 당사자가 주장하지 않더라도 기록상 신의칙 위반의 혐의가 있다면 법원은 이를 심리해야 할 의무가 있다.

2. 신의칙을 위반한 경우의 처리

- 당사자의 특정 소송행위가 신의칙에 반하는 경우 그 행위는 무효가 되어 효력이 발생하지 않는다. 예를 들어, 증거방해 행위가 있다면 방해된 증거의 가치를 상대방에게 유리하게 평가한다. 소의 제기 자체가 신의칙 위반(소권 남용, 실효, 부당형성 등)에 해당할 경우, 법원은 본안에 대한 심리를 거절하고 판결으로써 소각하 결정을 내려야 한다. 또한 신의칙 위반으로 인해 상대방에게 불필요한 비용이나 정신적 고통을 가했다면, 이는 실제법상 불법행위를 구성하여 별도의 손해배상 책임을 질 수 있다.

3. 간과판결과 그 구체

- 법원이 신의칙 위반 사실을 알지 못하고 본안판결을 내린 경우, 판결이 확정되기 전이라면 상소(항소, 상고)를 통해 신의칙 위반을 이유로 판결의 취소를 구할 수 있다. 판결이 확정된 후에는 기판력의 원칙상 이를 번복하기 어려우나, 판결의 편취와 같이 신의칙 위반의 정도가 극심하여 정의에 반한다고 인정되는 경우에는 재심사유에 준하여 다루거나, 판결에 기한 강제집행을 신의칙 위반으로 저지하는 청구이의의 소를 허용하는 것이 판례의 경향이다.

V. 결론

- 민사소송의 이상인 적정·공평, 신속, 경제의 가치는 법원의 적극적인 절차 운영과 당사자의 성실한 협력을 통해 달성될 수 있다. 신의성실의 원칙은 이러한 이상적 가치를 소송 현실에서 구현하는 통제 장치로서 작용한다. 다만, 신의칙은 일반조항으로의 도피라는 비판이 있을 수 있으므로, 명문의 절차 규정이 있는 경우에는 우선적으로 그에 따르되 규정의 공백이 있거나 규정의 기계적 적용이 현저히 부당한 경우에 한하여 보충적으로 적용되어야 할 경우도 있다. 법원은 구체적 타당성과 법적 안정성의 조화를 도모하며 신의칙을 엄격히 운용함으로써 사법 신뢰를 확보해야 할 것이다.